

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO-SUBSTITUTO MÁRCIO MARTINS DE
CAMARGO
TRIBUNAL PLENO - SESSÃO DE 12-06-2024 – MUNICIPAL
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

=====

Processo: TC-012023.989.24-7 (Ref.: TC-008482.989.24-1).

Recorrente: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista.

Assunto: **Pedido de Reconsideração** contra o acórdão do Plenário do Tribunal de Contas que considerou parcialmente procedentes as impugnações contra o edital da concorrência pública nº 20/2023, elaborado pela Recorrente, objetivando a *“concessão onerosa para implementação de pátio municipalizado para a prestação de serviços de remoção, guarda, liberação e vistoria de veículos automotores, caçambas, contêineres e similares e outros tracionados apreendidos e/ou removidos por descumprimento da legislação municipal ou infração de trânsito, como também a demanda das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN-SP presentes no Município”*, bem como determinou a anulação do procedimento licitatório, por apresentar vícios insanáveis.

Responsável: Amauri Sodré da Silva (Prefeito).

Subscritor do edital: Rogério Crantschaninov (Secretário Municipal de Mobilidade Urbana).

Advogado cadastrado no e-TCESP: Gustavo Lambert Del Agnolo (OAB/SP 302.235).

=====

EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. CONCESSÃO ONEROSA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PÁTIO MUNICIPALIZADO PARA A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA, LIBERAÇÃO E VISTORIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AFINS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL AUTORIZANDO A CONCESSÃO. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.987/95. INDEVIDA UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA REVOGADA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. VÍCIOS DE ORIGEM. ANULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ALTERAR O DECISÓRIO. NÃO PROVIMENTO.

01 – RELATÓRIO

1.1 Em apreciação **Pedido de Reconsideração** interposto pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**, contra a decisão plenária de 24-04-2024, que julgou parcialmente procedentes as impugnações em face do edital do Pregão Eletrônico DGA nº 1184/23, por ela elaborado, para a *“contratação de parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, para execução de serviços integrados de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição final de resíduos sólidos gerados no município”*.

Naquela oportunidade, o E. Tribunal Pleno, afora constatar a existência de vícios insanáveis relacionados ao descumprimento dos preceitos legais que regem as parcerias público-privadas e as contratações destinadas ao saneamento e à indevida utilização, ainda que subsidiária, da revogada Lei federal nº 8.666/93, determinou à Administração que, em eventual novo certame, adotasse as medidas corretivas pertinentes para dar cumprimento à lei, em especial:

- “a) Reavaliar a modalidade eleita, caso seus estudos concluam pela cobrança de tarifas;*
- b) Proceder à atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;*
- c) Indicar autarquia independente para regulação e fiscalização do ajuste;*
- d) Revisar os critérios da pontuação técnica;*
- e) Compatibilizar as fórmulas de cálculo das Notas Técnicas e Notas Comerciais, deixando de limitar a pontuação destas últimas;*

- f) Suprimir a requisição de prova, para fins de qualificação técnica, de atividades passíveis de subcontratação;*
- g) Reavaliar a possibilidade de participação de empresas reunidas em consórcio;*
- h) Limitar a exigência de registro no CREA à empresa líder para os casos de consórcios heterogêneos;*
- i) Excluir a exigência de comprovação de que o engenheiro responsável técnico das proponentes possua expertise em serviços de varrição manual de vias e logradouros públicos;*
- j) Adotar o valor dos investimentos estimados como base de cálculo para a prova de patrimônio líquido;*
- k) Possibilitar a participação de empresas em recuperação judicial, nos termos da Súmula nº 50;*
- l) Prever todas as hipóteses legais de autenticação de documentos, recomendando-se, ainda, que reveja a imposição de firma reconhecida”.*

1.2 Inconformada com a decisão, a **PREFEITURA** interpôs **pedido de reconsideração**, especificamente para rever a determinação de anulação do certame pela ausência de lei municipal que autorizasse a concessão.

Sustentou que o voto guerreado *“incorre em grave ofensa ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que subordina a gestão de serviços públicos, competência exclusiva do Poder Executivo, à aprovação prévia do Poder Legislativo”*, bem como *“viola a independência funcional e administrativa do Poder Executivo, comprometendo a eficiência e a celeridade na prestação dos serviços públicos”*.

Por outro lado, defendeu que *“a regulamentação de concessão de serviços públicos por decreto, nos moldes do realizado pelo Município de Bragança Paulista é possível e adequada, sendo certo que, o normativo limitou-se a detalhar e especificar a aplicação das diretrizes estabelecidas na legislação federal inerente ao assunto, não havendo assim qualquer irregularidade por parte da Municipalidade”*.

1.3 O **Ministério Público de Contas** manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, pois as *“razões recursais buscam encampar a tese de legalidade do edital em análise, sem, contudo, carrear aos*

autos fatos e/ou documentos novos capazes de alterar o juízo de irregularidade”.

Outrossim, entendeu que “a recorrente se limita, ainda que com abordagem mais aprofundada, praticamente a reproduzir os mesmos argumentos esposados na instrução do feito, os quais já foram analisados para o julgamento da matéria”.

Além disso, afastou a tese de que a edição de Decreto municipal, regulamentando a concessão no Município, seria suficiente para atender ao comando do art. 175 da Constituição Federal e do art. 2º, *caput*, da Lei n.º 9.074/1995, eis que tais normas são categorias em reclamar a existência de lei autorizadora específica para a concessão de serviços públicos.

É o relatório.

2. PRELIMINAR

2.1 O v. acórdão foi publicado no DOE de 02-05-2024 e o recurso interposto em 21-05-2024. Tempestivo, portanto.

2.2 Satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento.

3. VOTO

3.1 A decisão combatida deve subsistir, porquanto as razões recursais não prosperam.

3.2 Com o devido respeito a todo o esforço argumentativo da recorrente, impende destacar que o decisório apropriadamente constatou aspectos que impediam a continuidade do certame nos moldes propostos.

Nesse sentido, afora identificar a indevida utilização, ainda que subsidiária, da revogada Lei federal nº 8.666/93, ressaltou a ausência de lei municipal autorizadora da concessão pretendida.

Na oportunidade, destacou-se apontamento do MPC no sentido de que, *“embora a Administração tenha editado o Decreto nº 4.352, de 27-12-23, para regulamentar a concessão no município, ‘deve-se ter em vista que tanto a Constituição Federal quanto a Lei nº 8.987/1995, prescrevem que a concessão ou permissão de serviços públicos deve estar prevista em LEI’”*.

Ressalvou-se, assim, não ser *“possível aceitar que a concessão pretendida se fundamente em ato de natureza meramente administrativa do Chefe do Poder Executivo, hierarquicamente inferior à Lei Ordinária, requerida pelas normas que regem a matéria”*.

O voto também relembrou que este E. Plenário, ao analisar situação similar no processo TC-8646.989.15-2¹, concluiu pela inviabilidade do prosseguimento do certame, nos seguintes termos:

“A Municipalidade não logrou demonstrar a existência de lei autorizadora específica para a concessão onerosa dos serviços públicos de administração, remoção e guarda de veículos infratores à legislação.

(...)

Deste modo, ausente comprovação em sentido contrário nestes autos, compete reconhecer a infringência ao comando do artigo 2º, caput, da Lei nº 9.074/95, encontrando-se o Município de Guarulhos, portanto, desprovido de autorização legislativa para executar os serviços públicos de administração, remoção e guarda de veículos infratores à legislação por meio de concessão.

Por concatenação lógica, se ausente autorização legal para a celebração do contrato de concessão, não se pode permitir o prosseguimento do certame em apreço.

A questão tem caráter de prejudicialidade e determina, por si só, a necessidade de se determinar que à Prefeitura anule a concorrência e o edital respectivo (...).”

¹ Sessão Plenária de 09-12-15. Relator Conselheiro DIMAS RAMALHO

Ora, como se vê, o julgamento fundamentou-se na verificação da carência de lei específica que autorizasse a concessão pretendida, faltando-lhe, portanto, pressuposto legal para sua validação.

Sobre o tema, ressalto que o artigo 2º da Lei nº 9.074/95, que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos, é categórico em vedar que a *“União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe os termos, (...)”* (grifei).

Por sua vez, as razões recursais procuraram encampar a tese de legalidade do edital em análise, reproduzindo, ainda que com uma abordagem mais aprofundada, os mesmos argumentos apresentados durante a instrução do feito, que foram devidamente analisados para o julgamento da matéria.

Além disso, o apelo é desprovido de qualquer inovação fática ou documental que pudesse alterar o decisório atacado.

Quanto ao teor de sua tese, destaco que a simples edição do Decreto municipal n.º 4.352, de 27/12/2023, que regulou a concessão no município, não se mostra suficiente para afastar o juízo de irregularidade da matéria, porquanto a Carta Magna e Leis acima mencionadas são categóricas em afirmar que a concessão de serviços públicos demanda a prévia existência de lei autorizadora específica, o que não ocorreu no caso.

Ademais, como destacou o Órgão Ministerial, *“cabe observar que a determinação contida no voto impugnado se refere a edição de ‘LEI’ que autorize a concessão dos serviços e não à imposição de “autorização” prévia do Poder Legislativo para a realização da licitação”*.

3.3 Ante o exposto, e por tudo o mais consignado nos autos, meu voto **NEGA PROVIMENTO** ao Pedido de Reconsideração.

Sala das Sessões, 12 de junho de 2024.



TCE-SP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
(11) 3292-3531 (11) 3292-3368 - gcseb@tce.sp.gov.br



MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO